

1500291-21.2021.8.26.0573

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Regina Figueiredo

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... entendimento da jurisprudência:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. LOCALIDADE DOMINADA POR FACÇÃO CRIMINOSA. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NO GRUPO CRIMINOSO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA ASSOCIAÇÃO. 1. Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça entendimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

2ª Vara

Rua Ettore Targa, s/n, São Manuel - SP - cep 18650-000

1500291-21.2021.8.26.0573 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500291-21.2021.8.26.0573

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADILSON APARECIDO PAES CAMILO e outro

Vistos.

ADILSON APARECIDO PAES CAMILO e SKARLETY JULIETE BARRA, qualificado nos autos digitais, foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, porque no dia 11 de outubro de 2021, por volta da 15h45min, na Rua Capitão Maneco nº 1, Área Rural, na cidade de Pratânia, traziam consigo 10 (dez) pedras de "crack", além de R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) em moeda corrente, droga destinada ao consumo de terceiras pessoas que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão e laudo de constatação juntados aos autos.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo os acusados supracitados, associaram-se, na forma do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343 de 2006.

Os réus foram presos em flagrante delito e o expediente policial distribuído ao d. Juízo Plantonista da 23ª CJ da Comarca de Botucatu que, após a manifestação das partes, decidiu pela conversão da prisão em flagrante em preventiva (p.71/73). Comunicação do indeferimento da liminar pleiteada em sede de habeas corpus nas p.149/151.

Oferecida denúncia aos dias 26 de outubro de 2021, os réus foram devidamente notificados às p.168 e 170, e ofertaram defesa preliminar na p. 175, sendo a

denúncia recebida por decisão datada de 02 de dezembro de 2021 (p. 186/187). Durante a instrução, realizada por videoconferência conforme Comunicados e Provimentos em vigor, na qual foram ouvidas três testemunhas arroladas na denúncia e interrogados os réus ao final, conforme gravação audiovisual juntada aos autos eletrônicos.

Encerrada a instrução criminal, a i. Representante do Ministério Público apresentou suas alegações finais orais, requerendo a condenação dos acusados nos termos da exordial, com a fixação do regime inicial de cumprimento de pena como fechado.

A n. Defesa técnica dos réus, a seu turno, por meio de memoriais escritos, pugnou a absolvição diante da fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, pugnou a desclassificação do delito imputado aos réus na denúncia para o de porte de entorpecentes para uso próprio. Alternativamente, em caso de condenação, postulou o reconhecimento da menoridade relativa dos réus e de suas confissões exaradas ainda em solo policial, com a aplicação da pena no mínimo legal, convertendo-se a pena corporal por restritivas de direitos ou sursis penal e fixando-se regime inicial aberto para cumprimento de eventual pena. (p.258/262).

É o breve relatório.

DECIDO.

Não havendo questões preliminares ou de admissibilidade a analisar e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A procedência parcial do pedido inicial é medida que se impõe, senão vejamos:

A materialidade restou suficientemente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de p. 05/06, Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida de p. 07/09, Auto de Exibição e Apreensão de p. 20/21 e Laudo Químico-Toxicológico Definitivo de p. 164/166, que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida com resultado positivo para cocaína na forma de crack.

No tocante à autoria, observo que, na fase pré-processual, ambos os réus confessaram que, antes da abordagem policial haviam vendido uma porção de crack e comprado dois salgados com o dinheiro da venda, sobrando os R\$2,50 que foram apreendidos (p.13/14 e 15/16).

Já quando de seu interrogatório judicial, o réu Adilson Aparecido Paes Camilo negou os fatos narrados na denúncia, alegando que foi com sua namorada Skarlety passar uns dias na casa da tia dela, nacidade de Pratânia, onde adquiriu dez porções de crack para ambos consumirem, com dinheiro proveniente dos 'bicos' de servente de pedreiro que fazia com seu tio. Que na tarde dos fatos, ao avistar uma viatura policial, passou essa droga para sua namorada, pois sabia que não havia policial feminina na cidade, após o que ambos foram abordados. Que uma policial feminina foi acionada e localizou a droga com Skarlety e os policiais falaram que se não assumisse a traficância, ela seria presa, motivo pelo qual acabou confessando.

De igual forma, a ré Skarlety Juliete Barra negou a veracidade da acusação, alegando que, estava com seu namorado na praça pública de Pratânia, quando ambos foram abordados por policiais que localizaram as dez porções de crack na sua cintura e que haviam acabado de adquirir, com dinheiro emprestado, para consumirem juntos

Já o policial militar Carlos Jose Ferreira dos Santos, relatou que, na data dos fatos, realizava patrulhamento de rotina e, ao passar pela praça central de Pratânia, avistou um casal que, até então, desconhecia e, ao indagar o réu, ele respondeu que era da cidade de Areiópolis e não portava documentos, motivo pelo qual foi realizada busca pessoal nele e localizado apenas R\$2,50, enquanto que a policial feminina Silvana realizou busca pessoal na ré Skarlety e localizou dez porções de crack na cintura da sua calça. Após ser questionado, o réu admitiu que estavam traficando e haviam vendido uma porção da droga pelo valor de R\$10,00, com o qual compraram dois salgados, sendo apreendido o que sobrou de troco.

No mesmo sentido foram as declarações dos também policiais militares Rodrigo Teixeira da Costa e Silvana Maria Morelli, acrescentando o primeiro que o local em que os réus foram abordados é conhecido como ponto comum de tráfico e que, durante a busca pessoal realizada em Adilson, Skarlety demonstrou nervosismo e, por isso,

acionaram o apoio da policial Silvana para realizar busca pessoal nela que, a seu turno, permaneceu em silêncio após a apreensão das porções de droga em seu poder. Pois bem.

A cabo da instrução criminal, nota-se que a negativa de autoria sustentada pelo réus, sob a frágil alegação de que a droga apreendida se destinava ao próprio consumo de ambos, além de inconvincente, revela a nítida tentativa de se eximirem das responsabilidades criminais pela prática da traficância.

Isso porque o acusado Adilson alegou em juízo que somente assumiu a destinação da droga apreendida ao tráfico para que sua namorada Skarlety não fosse presa pelos policiais militares; contudo, mesmo ela sendo conduzida ao Distrito Policial, tem-se que o acusado tornou a confessar a traficância perante a d. Autoridade Policial, no que foi seguido pela própria acusada (p.13/14)

Ora, se a versão apresentada pelos acusados fosse verdadeira, não haveria qualquer motivo para eles também admitirem a prática do tráfico durante o interrogatório na Delegacia de Polícia.

Ademais, enquanto o réu Adilson declarou que adquiriu as drogas apreendidas com dinheiro que recebeu de seu tio pelos seus serviços que prestou como servente de pedreiro, a ré Skarlety, em contrapartida, alegou que adquiriram as drogas com dinheiro que havia emprestado, revelando, pois, nítida contradição nas suas versões, razões pelas quais suas negativas de autoria não merece qualquer credibilidade.

A propósito, a alegação dos réus em juízo de que são apenas usuários já se tornou comum em se tratando de traficantes surpreendidos com drogas, no intuito de suavizar a situação e conseguir uma pena de advertência, prestação de serviços comunitários ou, quiçá, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, que são aquelas previstas para o usuário de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

Ressalte-se que o delito em tela restou plenamente consumado ainda que os réus não tenham efetivamente comercializado drogas em virtude da pronta e eficiente ação da polícia que os prenderam em flagrante antes disso, já que o artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 prevê um tipo penal de ação múltipla alternativa, de modo que a realização de apenas uma das condutas nele descritas já é suficiente para a sua configuração, como a praticada pelos acusados de trazerem consigo drogas destinadas ao consumo de terceiros pessoas.

A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.(REsp 1708569)

Por outro lado, relativamente ao delito do artigo 35, caput, da Lei Antidrogas, entendo que o vínculo associativo para o tráfico, de maneira estável e duradoura, como se exige, não restou suficientemente caracterizado nos autos, na medida em que não houve campana ou uma investigação mais duradoura que demonstrasse a união de esforços e a divisão de tarefas entre os réus, sendo certo que a simples reunião esporádica é insuficiente para caracterizar o delito em questão.

Na verdade, “não será toda vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris*, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria” (in Tóxicos, Vicente Greco Filho, Editora Saraiva, 14ª edição, p. 209/210).

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. LOCALIDADE DOMINADA POR FACÇÃO CRIMINOSA. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NO GRUPO CRIMINOSO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA ASSOCIAÇÃO. 1. Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que é indispensável, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. 2. Ainda que seja de conhecimento o domínio da

localidade por facção criminosa, não há na denúncia, na sentença ou no acórdão nenhum apontamento de elementos concretos indicativos da estabilidade e permanência dos réus na associação criminosa voltada à comercialização ilícita de drogas, havendo a indicação apenas do concurso de agentes em crime de tráfico. 3. Habeas corpus concedido, para restabelecer a sentença de primeiro grau em que se absolveu o paciente da prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 (art. 386, VII – CPP), mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, c/c art. 40, incisos VI, ambos da Lei 11.343/2006) e a consequente pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e 583 dias-multa, no valor unitário.” (HC 682.097/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 05/11/2021)

O fato é que, nesse ponto da acusação, não se desincumbiu o Estado do ônus de comprovar cabalmente nos autos a suposta associação estável dos acusados para a prática da traficância, não se conformando o Direito Penal com menor indícios e suposições para corroborar um decreto condenatório, devendo prevalecer a máxima do princípio in dubio pro reo para que sejam absolvidos.

Assim, de rigor a parcial procedência da ação penal para que os réus sejam condenados tão somente como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 cc artigo 29, do Código Penal (concurso de agentes).

Passo a dosar as penas.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/06, notadamente a primariedade técnica dos acusados (p.42/45 e 209/211-Adilson e 46/49 e 212/214-Skarlety) e a pequena quantidade da droga apreendida (2,86g de massa líquida cf. p.37), fixo a pena base no mínimo legal, a saber, 5(cinco) anos de reclusão e 500(quinhetos) dias multa.

Deixo de considerar a confissão espontânea dos acusados, ainda em solo policial, bem como as suas menoridades relativas (p.22), tendo em vista que a pena base foi fixada no mínimo legal não poder ficar aquém desta por força da Súmula n. 231 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Não há circunstâncias agravantes a considerar, tampouco causa de aumento de pena.

Presente a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pois os réus são primários, não ostentam condenações criminais anteriores e inexistente nos autos prova de que se dediquem à atividades criminosas ou íntegra organização criminosa.

Logo, à míngua de elementos probatórios que indiquem a habitualidade delitiva dos acusados e diante da apreensão de pequena quantidade de entorpecente, tenho que a pena deve ser reduzida no patamar máximo, resultando em 1(um)ano e 8(oito) meses de reclusão e 166(cento e sessenta e seis dias) multa.

Assim sendo, torno as penas definitivas em tal patamar.

À míngua de maiores elementos sobre a situação econômica dos réus e diante das suas aparentes hipossuficiências, fixo no patamar mínimo o valor do dia-multa.

Anoto que os réus permanecem presos desde o dia 11 de outubro de 2021 (p.07), logo, a pena privativa de liberdade que resta a ser cumprida é de 1(um) ano, 2(dois) meses e 09(nove) dias de reclusão (CPP, art. 387, §2º, com redação dada pela Lei n. 12.736/12).

Quanto ao regime prisional inicial, observo que na decisão proferida pelo Plenário da Corte Suprema (STF - HC 118.533/MS - Rel. Min. Carmen Lúcia), entendeu-se que a figura do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei nº

11.343/06, não se harmoniza com a qualificação de hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e parágrafo 1º do artigo 33 do mesmo Diploma.

Muito embora possam existir respeitáveis discussões acadêmicas quanto ao mérito da referida decisão, entendo, com a devida ressalva a entendimentos contrários, que não cabe a este Juízo deixar de reconhecer força a referido precedente, igualmente adotado pela 3ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo cadastrado como Tema 600, cancelando, por consequência, a Súmula n. 512, editada em 2014.

Assim sendo, curvo-me ao entendimento jurisprudencial pacificado para reconhecer o afastamento da hediondez da conduta do acusado e, por consequência, fixar o regime

aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, à luz do que dispõe o artigo 33, §3º, do Código Penal.

No que diz respeito à substituição da pena corporal por restritivas de direitos, apesar da recente Resolução nº 5 editada pelo Senado Federal, através da qual ficou suspensa a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", presente no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a mesma não se mostra medida suficiente e adequada no caso concreto, haja vista a postura indiferente adotada pelo agente diante dos efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas à saúde pública e ao bem estar social, o que vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal.

Vale lembrar que os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, são cumulativos, devendo estar integralmente presentes para que seja concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o que não se verifica na espécie, sendo, portanto, inadmissível.

Deixo de fixar indenização por danos materiais em valor mínimo, pois o delito em apreço não gera efetivo prejuízo material mensurável economicamente.

Por fim, considerando o término da instrução criminal, o montante da pena aplicada a ser cumprida no regime inicial aberto e a primariedade dos acusados, faculto-lhes aguardarem eventual julgamento de recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os acusados ADILSON APARECIDO PAES CAMILO e SKARLETY JULIETE BARRA como incurso no artigo 33, caput, c.c. o §4º, da Lei nº 11.343/06 cc artigo 29 do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1(um) ano e 8(oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, além da pena pecuniária de 166(cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, facultando-lhe o apelo em liberdade, bem como para absolvê-los da imputação feita na denúncia como incurso no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Expeçam-se, com urgência, alvarás de soltura clausulado.

Observe-se o contido no artigo 400 das NSCGJ, se o caso.

Arcarão os réus com as custas processuais no valor correspondente à 100 UFESP's, ficando deferida a gratuidade processual (p.180/181), observando-se o quinquídio legal.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, declaro a perda do numerário apreendido nos autos à p.109 em favor da União.

Com o trânsito em julgado, oficie-se para destruição das amostras guardadas para contraprova conforme o disposto no art. 525 das NSCGJ-" Encerrado o processo penal ou arquivado o inquérito policial ou termo circunstanciado, o juiz determinará a destruição das amostras guardadas para contraprova, não podendo os autos serem remetidos ao arquivo sem a respectiva comunicação."

P. I.C.

São Manuel, 25 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA